

1501688-37.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Também foi condenado pelo grave delito de tráfico de drogas no processo 0022139-34.2012.8.26.0451, novamente dessa 1ª V.C., cuja pena ainda está pendente de cumprimento (fls. 165 da F.A.).

Por outro lado, Carlos tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime.

Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir suas penas na segunda fase.

Ozeias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501688-37.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2299524/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 21184634 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 3116/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2299524 - 02º D.P. PIRACICABA, 3116/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA, 2299524/2021 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS AUGUSTO HORACIO JUNIOR e outro

Réu Preso

Contr. nº 2021/001167

Aos 12 de setembro de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Mariana Bernardes Andrade foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presentes os réus CARLOS AUGUSTO HORACIO JUNIOR (preso no CDP de Piracicaba) e OZEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA. Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comum: PM WALLACE AUGUSTO OLIVEIRA PATARRO. Ausente a testemunha(s) comum: PM Fernanda Orestes Silva.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com os acusados e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pelo acusado Ozeias foi informado seu endereço, a saber: Rua Gomes Carneiro nº

1402, no prédio abandonado, próximo ao Teatro Municipal.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Wallace) e em seguida os interrogatórios dos réus foram gravados em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) PM Fernanda, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).CARLOS AUGUSTO HORACIO JUNIOR e OZEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, §§1º e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 4 de novembro de 2021, por volta dos 20 minutos, na rua Dom Pedro I nº 1.656, nesta cidade e comarca, os acusados, em concurso, subtraíram para si, durante o repouso noturno, mediante escalada, 11 barras de alumínio, avaliadas em aproximadamente R\$ 3.900,00, pertencentes à imobiliária "BEVI". É da inicial que os denunciados se uniram para a prática do furto e, por ocasião dos fatos, aproveitando-se do período de repouso noturno, compareceram à sede da imobiliária "BEVI", escalaram o prédio para alcançar a sobreloja e subtraíram para si as barras de alumínio que protegem a janela, levando-as aos poucos para local seguro (fls. 16). Vizinhos do estabelecimento notaram a subtração e acionaram a Polícia Militar. Em diligências pelas imediações, os PMS se depararam com os indiciados na via pública, carregando algumas das peças retiradas do estabelecimento; próximo de onde estavam foram localizadas e apreendidas as unidades subtraídas anteriormente. Nesse contexto, ambos foram presos em flagrante delito. O processo teve trâmite regular. A ação penal procede em parte. A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/14; auto de exibição e apreensão de fls. 15; fotografias de fls. 16; auto de avaliação e entrega de fls. 17/18; laudo pericial do local de fls. 183/188; e depoimentos colhidos. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. A vítima Maria Cynthia contou, na polícia, que é proprietária da imobiliária. Na data dos fatos, recebeu ligação da vizinha informando ter ouvido barulho em seu estabelecimento. Ao consultar as imagens das câmeras de segurança, viu dois indivíduos acessando o local. Por fim, confirmou que os acusados furtaram as barras de alumínio que protegiam a janela frontal da imobiliária. Em Juízo, a vítima contou que era madrugada. Uma vizinha ouviu um barulho. Eles estavam tirando o alumínio e levando até um ponto de ônibus. A vizinha acionou a Polícia. Os PMS chegaram e, pelo o que viu das imagens, pegaram os agentes na esquina. Encontraram o material que eles tinham deixado no ponto de ônibus. As barras retiradas foram descartadas, eram alumínio, não tinha como recuperar. As barras começavam do chão e lá são dois andares. A câmera da vizinha pegou a ação. Chegou a ver as imagens e constatou que as pessoas que foram presas eram aquelas que praticaram o furto. Inclusive, estavam correndo com o objeto. Não teve dúvida nenhuma com relação a autoria dos dois. Não sabe falar de altura, mas tem uma janela de vidro que dá acesso ao interior do escritório. Exibida a imagem de fl. 150, disse que as barras removidas ficavam atrás da planta que aparece na fotografia. Eles não precisaram remover as plantas, pois as plantas não estavam da altura que aparece na imagem. Não houve acesso ao interior do estabelecimento. O ponto de ônibus onde estavam as barras fica na esquina do local. Eles não chegaram a retirar todas as barras. Reiterou que as barras que foram removidas eram as que estavam atrás da planta da fotografia de fl. 150, mais para baixo, e não as de cima. Em Juízo, o PM Wallace disse que foram solicitados via COPOM. A denúncia informava que dois indivíduos estavam furtando barras de alumínio naquele momento, passando as características deles. No local, viram dois indivíduos com as mesmas características com as barras de alumínio. Eles tentaram se esconder, mas foram localizados na Rua Riachuelo. Eles falaram que havia outras barras e que estavam escondidas, indicando o local.

Além daquelas que eles soltaram, foram fazer a diligência no local por eles indicados, onde acabaram encontrando as outras barras. Quando os viram os dois estavam carregando as barras de alumínio. A solicitante era uma vizinha. Ela relatou que os indivíduos estavam ali mesmo e se evadiram do local assim que ele chegou. Ela não quis ter contato com os dois e pediu para ficar no sobrado da casa dela, com medo de represálias. As janelas de onde eles retiraram as barras de alumínio eram no terço, acreditando o declarante que são barras decorativas. Não visualizou eles escalando nada. Os réus não confessaram que furtaram as barras, mas indicaram onde estavam as barras escondidas. Confirma que os informes fornecidos na denúncia, no tocante às características deles, batiam com as características vistas no dia. Os réus iam e voltavam. Não conseguiram retirar tudo de uma vez, então eles foram retirando aos poucos. A vizinha chegou a ver eles indo e voltando. O local da abordagem era próximo ao local da subtração. Na janela ainda tinham outras barras, não conseguiram retirar todas. Em solo policial, a PM Fernanda confirmou o relato do companheiro de farda, Disse que a denúncia transmitia as características dos furtadores, tendo a solicitando informado que eles estavam aparentemente deixando as barras em alguma localidade, pois deixavam o local e depois retornavam. No local, viram os dois indivíduos carregando barras de alumínio, que possuíam as mesmas características transmitidas pela solicitante. Ademais, ao avistar as viaturas, tais indivíduos soltaram as barras e tentaram se esconder, sendo localizados na Rua Riachuelo. Por fim, afirmou que, além das barras deixadas pelos indiciados, foram localizadas outras barras escondidas nas imediações. No interrogatório policial, CARLOS e OZEIAS disseram que estavam usando "crack" e viram algumas pessoas jogando as barras de alumínio no chão, decidindo pegá-las. No entanto, acabaram surpreendidos com a chegada da polícia militar. Perante a MM. Juíza, CARLOS declarou que estava muito alucinado pelo uso de drogas e "acredita" ter "roubado" as barras de alumínio. Disse, no entanto, que não tinha como escalar prédio. Declarou, por fim, que OZEIAS estava junto. OZEIAS também confessou os fatos, negando ter escalado alguma parede para subtrair as barras. Sem controvérsia fática, a condenação é de rigor, com a seguinte ressalva: as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo não ficaram caracterizadas. A vítima explicou que a janela atingida é a do pavimento inferior e que não houve ingresso no estabelecimento. De outro bordo, o furto foi consumado, pois os réus já tinham subtraído parte das barras de alumínio e escondido a res pelas imediações, apontando aos policiais o local onde estavam. Sabe-se que o Plenário do STF, superando o debate em torno do tema, adota a teoria da "apprehensio" (ou "amotio") para considerar consumada a subtração quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, mesmo quando seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude da perseguição imediata. A tese jurídica aplicável ao caso também está definida pelo STJ nos termos do art. 543-C do CPC: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da 'res furtiva', ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450 - RJ - 2015/0073105-7, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2015). No tocante à pena, verifica-se que CARLOS possui antecedentes desabonadores e é reincidente. Por ocasião do fato, cumpria pena em regime aberto (fl. 109 - TCP previsto para 15/04/23). Assim, deve ser imposto o regime fechado para o desconto da pena. Na terceira fase, deve incidir a majorante do repouso noturno. O réu OZEIAS não possui antecedentes desabonadores (fls. 110/111). Pode ser imposto o regime aberto, com substituição por pena alternativa. Pelo exposto, requer-se a procedência parcial da presente ação penal, condenando-se os réus por furto qualificado pelo concurso de agentes. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). CARLOS AUGUSTO HORÁRIO JUNIOR e OZEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA vem processados pela prática do crime previsto no artigo 155 §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal, conforme os fatos descritos na inicial acusatória. O processo teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. À vista das provas produzidas, o Ministério Público requereu a condenação dos dois acusados. Ocorre, porém, que é caso de julgar a ação penal improcedente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Os réus estão sendo processados porque teriam subtraído, mediante

escalada e durante o repouso noturno, barras de alumínio da imobiliária "Bevi". A vítima, no entanto, quando ouvida, afirmou que nada presenciou, pois apenas soube do ocorrido por uma vizinha. As barras eram subtraídas e levadas até um ponto de ônibus. Segundo a vítima, as barras serviam para proteger a janela frontal da imobiliária. Já os policiais militares que os prenderam em flagrante relataram que apenas os surpreenderam quando caminhavam pela via pública trazendo consigo barras de alumínio, isto após a denúncia de que dois indivíduos estariam as subtraindo de uma imobiliária. Assim, nota-se que a prova é frágil, pois a prova produzida em desfavor dos acusados consiste nos depoimentos dos policiais militares, que obviamente tendem a justificar seus atos, não se podendo falar, portanto, que seus testemunhos são totalmente isentos. Nesse sentido: "As palavras dos policiais merecem credibilidade, mas não basta o título (exercício da função de policial). Há necessidade de que estas tenham apoio em evidências circunstanciais e testemunhais, sob pena de exaltar-se um registro indiciário como absoluto, infalível e inquestionável". (TJSP - 7ª Câmara - Ap. Cr. n. 1.465.651/6 - Com. de Campinas - j. 19/5/2005 - v.u.). Logo, necessário que outras provas viessem a ser produzidas, especialmente o testemunho de pessoas estranhas ao quadro policial, como, por exemplo, a pessoa que teria acionado a polícia. No caso em tela, o único civil ouvido foi a vítima, que nada presenciou e pouco pode esclarecer. Além disso, o simples fato de estarem em poder das barras não conduz automaticamente à conclusão de que foram eles os autores do furto, pois podem ter recebido o objeto de alguma outra forma. Não há que falar em inversão do ônus da prova ou presunção de autoria, pois a única presunção possível no processo penal é a de inocência, a qual não foi infirmada pelas provas reunidas ao longo da persecução penal. Assim, a prova da autoria delitiva é frágil, motivo pelo qual ambos devem ser absolvidos, nos termos do art. 386, VII, do CPP. No entanto, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação dos acusados, requer-se inicialmente o afastamento da qualificadora da escalada, que não restou comprovada. Pelo que se verifica às fls. 183/188, as barras que foram subtraídas estavam em local mais baixo, de modo que não houve emprego de esforço anormal. O policial ouvido na audiência de hoje também relatou que as barras estavam "no térreo" e que não houve escalada. Tudo isso afasta a qualificadora em questão. No mais, de rigor a fixação da pena no mínimo legal. Em favor deles há a atenuante da confissão, o que neutraliza circunstâncias agravantes ou desfavoráveis. Na terceira fase da aplicação da pena, a defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno, ante sua incompatibilidade com a figura do furto qualificado. Neste sentido cabe registrar que recentemente o C. STJ, por meio de sua Terceira Seção, alterou o entendimento que até então vinha adotando. Assim, em sede de julgamento de recursos repetitivos fixou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1087). A ementa do julgamento, a propósito, foi assim redigida: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido". (Resp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira

Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022). Logo, trata-se de precedente vinculante, que deve ser observado pelos juízes e tribunais. Ainda na terceira fase da aplicação da pena, requer-se seja reconhecido o crime tentado, posto que, pelo que se apurou, os réus ainda não haviam esgotado a ação. Ainda que algumas barras tivessem sido retiradas, certo é que os agentes ainda pretendiam levar as demais, tanto que surpreendidos nas imediações. Nesse sentido o depoimento da vítima de que os indivíduos ainda executavam o crime quando detidos. Logo, o crime tentado tem que ser reconhecido, com a respectiva redução de pena. Por fim, inobstante os apontamentos criminais existentes, requer-se a fixação de regime inicial diverso do fechado para Carlos, com base na Súmula 269, do STJ. Já Ozeias é primário e faz jus a todos os benefícios legais, como a fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto para o caso de conversão. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, requer-se seja conferido a ambos o direito de recorrer em liberdade, se assim desejarem.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

CARLOS AUGUSTO HORACIO JUNIOR e OZEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA, nos autos qualificados, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 155, § 1º c.c. § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 4 de novembro de 2021, por volta dos 20 minutos, na rua Dom Pedro I nº 1.656, nesta cidade e comarca, em concurso, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, mediante escalada, 11 barras de alumínio, avaliadas em aproximadamente R\$ 3.900,00, pertencentes à imobiliária "BEVI" (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 15, auto de avaliação e entrega de fls. 17/18 e fotografias de fls. 16/17).

Narra a denúncia que os acusados se uniram para a prática do furto e, por ocasião dos fatos, aproveitando-se do período de repouso noturno, compareceram à sede da imobiliária "BEVI", escalaram o prédio para alcançar a sobreloja e subtraíram para eles as barras de alumínio que protegem a janela, levando-as aos poucos para local seguro (fls. 16). Vizinhos do estabelecimento notaram a subtração e acionaram a Polícia Militar e, em diligências pelas imediações, os PMS se depararam com os acusados na via pública, carregando algumas das peças retiradas do estabelecimento. Próximo de onde estavam foram localizadas e apreendidas as unidades subtraídas anteriormente. Nesse contexto, os acusados foram presos em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 11/11/2021 (fls. 173).

O réu Carlos Augusto foi citado (fls. 205). Defesa preliminar apresentada às fls. 211/214. Após, foi mantido o recebimento da denúncia em relação a ele (fls. 223/224).

Quanto ao acusado Ozeias, foi citado por edital (fls. 327) e não respondeu a citação e nem constituiu defensor, o que ensejou a suspensão do processo em relação a ele nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com determinação de antecipação de provas (fls. 340). Posteriormente localizado, o réu foi citado regularmente (fls. 403) e apresentou defesa preliminar às fls. 407/410, revogando-se a suspensão processual, mantendo o recebimento da denúncia em relação a ele (fls. 413).

Durante a instrução foram ouvidas a representante da vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da parcial denúncia, com condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime, bem assim as majorantes do concurso de agentes e do repouso noturno.

A Defesa pleiteou a absolvição por falta de provas e, em caso de condenação, o afastamento da qualificadora da escalada e da majorante do repouso noturno, requerendo, ainda, o reconhecimento da tentativa.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede em parte.

A materialidade delitiva foi comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletim de ocorrência de fls. 12/14;
- 2) autos de exibição e apreensão (fls. 15), de entrega (fls. 17) e de avaliação (fls. 18), acompanhados da fotografia de fls. 16;
- 3) laudo pericial de fls. 183/188, o qual constatou danos de aspectos recentes na grade localizada na região anterior do imóvel (de onde foi subtraída a “res furtivae”).

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 06 e 09), o réu Carlos alegou que havia usado drogas e, no caminho, quando retornava para casa, viu algumas pessoas dispensando barras de alumínio no chão. Decidiu pegá-las, senão outra pessoa o faria.

Esclareceu que pretendia vendê-las no dia seguinte para comprar drogas, mas acabou sendo abordado pela polícia militar na posse dos objetos.

Interrogado em juízo (gravação), Carlos confessou o crime. Disse que, no dia dos fatos, usou droga e álcool de posto de gasolina. Não se lembra de tudo o que fez, mas admitiu que ele e Ozeias praticaram o furto das barras de alumínio. Negou, apenas, a escalada.

Por sua vez, o réu Ozeias declarou, na fase informativa (fls. 09), que é morador de rua e, no dia dos fatos, havia usado “crack”. Quando se dirigia para um prédio abandonado, visualizou algumas peças de alumínio jogadas no chão e resolveu pegá-las, mas, no caminho foi abordado por policiais militares.

Interrogado em juízo (gravação), Ozeias confessou o crime, dizendo que agiu em concurso com o corréu.

A confissão dos acusados foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase informativa (fls. 05) e sob o crivo do contraditório (gravação – fls. 354), a filha da proprietária da Imobiliária Bevi, Maria Cynthia Braz, declarou que, na madrugada dos fatos, uma vizinha que morava na casa situada em cima da imobiliária, ouviu barulho e percebeu que dois indivíduos estavam subtraindo as barras que protegiam uma janela de vidro do estabelecimento e as levando até o ponto de ônibus situado na esquina. Diante disso, ela acionou a Polícia Militar. Quando chegaram ao local, os policiais surpreenderam os furtadores e os detiveram, recuperando todo o material subtraído. Entretanto, as barras foram descartadas porque não puderam mais ser aproveitadas para o fim a que se destinavam. Esclareceu que teve acesso às imagens das câmeras da vizinha e, através delas, pode constatar que os réus, presos no dia, eram os mesmos indivíduos que praticaram a subtração. Visualizando a fotografia do local dos fatos, de fls. 150, apontou uma janela existente atrás das plantas, perto da numeração do imóvel, como sendo o local de onde os acusados subtraíram as barras de ferro. Acrescentou, por fim, que os réus não chegaram a ter acesso ao interior do estabelecimento.

O policial militar Wallace Augusto de Oliveira Pattaro declarou, na fase informativa (fls. 04) e em juízo (gravação), que foram acionados via COPOM para atenderem ocorrência de furto em andamento na imobiliária descrita na denúncia. De acordo com a solicitante, havia dois indivíduos furtando barras de alumínio de uma das janelas da mencionada imobiliária, os quais, após retirarem tais objetos, escondiam-nos em certo local e retornavam para subtrair mais barras. De posse das características dos furtadores, dirigiam-se até o local e avistaram os réus andando pela via carregando barras de alumínio, notando que eles possuíam as características indicadas pela solicitante. Afirmou que, ao avistarem a viatura, ambos soltaram os objetos e tentaram se esconder, mas acabaram sendo detidos. Disse que, além das barras dispensadas por eles no caminho, também encontraram outras escondidas nas imediações, as quais estavam em local indicado pelos próprios acusados. Por fim, informou que as barras estavam sendo retiradas da janela do pavimento inferior do imóvel, não sendo necessária escalada para a prática da subtração.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Fernanda Orestes Silva na fase informativa (fls. 03).

Anoto que os relatos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER – j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que os réus, agindo em concurso, praticaram o crime de furto que lhes foi imputado na denúncia.

De fato, ambos foram detidos por policiais militares logo após a prática delitiva e estavam na posse de parte da “res furtivae”.

Ademais, nas imediações de onde os réus foram abordados, os policiais encontram o restante das barras subtraídas, em local indicado pelos próprios acusados.

Há muito a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a apreensão da “res furtiva” na posse do agente após o cometimento do crime e a ausência de justificativa convincente para o fato fazem presumir a autoria delitiva.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição – Fragilidade –

Materialidade e autoria demonstradas – Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova – Pena reclusiva mantida – Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal – Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais – Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Ausência de recurso ministerial nesse sentido – Recurso parcialmente provido”. (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020) - g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Sentença condenatória – Pleito absolutório inadmissível – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível – Prova oral suficiente para a condenação – Eventual nulidade ocorrida na fase de inquérito que não macula o processo penal, até porque não houve qualquer prejuízo – Corréu que foi condenado pelo mesmo crime, nas mesmas circunstâncias fáticas, por esta c. Câmara Criminal – Princípio da insignificância e crime impossível inócuentes – Concurso de agentes caracterizado, tanto é que o comparsa já foi condenado definitivamente pelo mesmo crime- Dosimetria penal inalterada – Aumentos proporcionais e devidos – Inocorrência bis in idem, uma vez que foram enumeradas condenações distintas para caracterizar Maus antecedentes e reincidência – Regime fechado como único adequado em virtude da biografia criminal do réu – Apelação não provida. Sentença mantida”. (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021) - g.n.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Escalada. Materialidade e autoria comprovadas. Relato seguro e coeso de policial militar, a par da apreensão do bem na posse do réu corroborando a acusação. Qualificadora inquestionável. Condenação mantida. Tentativa. Redução da reprimenda condizente com o “iter criminis” percorrido. Regime aberto e substituição da corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Singela substituição por multa insuficiente à reprovação do delito. Recurso improvido”. (TJSP. Apelação Criminal 0001184-87.2018.8.26.0542. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Farto Salles - j. 02/03/2021) - g.n.

Acrescente-se a tais provas as confissões feitas pelos réus nesta audiência. De rigor, pois, a condenação de ambos pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, eis que o praticaram em conluio.

Entretanto, é caso de afastamento da qualificadora da escalada, eis que, conforme revelaram a perícia e a prova oral aqui analisada, os réus não tiveram que escalar o prédio para praticarem a subtração.

Também é caso de afastamento da majorante do artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal, eis que se trata de furto qualificado e, nessas hipóteses, conforme decidiu o E. STJ, não é possível a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno.

De fato, em 27/06/2022, o C. Superior Tribunal de Justiça publicou os acórdãos de mérito nos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n. 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema n. 1087 – Furto – Noturno – Incidência – Simples – Qualificada, com a seguinte tese:

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Afasto a tese defensiva de que ocorreu a tentativa.

Quando foram surpreendidos pelos policiais, os réus já haviam retirado a “res” do imóvel e se afastado do local do crime, tendo, inclusive, escondido parte das barras de alumínio em local próximo.

Consumaram, assim, a infração.

Fixada, dessa forma, a responsabilidade penal dos réus por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, passo à fixação das penas.

O réu Carlos ostenta Maus antecedentes, pois, conforme fls. 95 da certidão de objeto e pé, complementada pelas fls. 162 e 164 da F.A., foi condenado pelo crime

de roubo no processo nº 0026871-34.2007.8.26.0451 dessa 1ª V.C., com sentença transitada na data de 26/12/2007 e cuja pena foi julgada extinta em 05/09/2013. A teor do julgado pelo C. STF no RE 593818 (com repercussão geral reconhecida - Tema 150), referidas condenações não podem ser desprezadas.

De fato, no mencionado recurso extraordinário, decidiu a Corte Suprema que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, podendo subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis. Assim, fixo as penas-base de Carlos 1/6 acima do mínimo, o que perfaz dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa.

Em relação ao acusado Ozeias, primário e de bons antecedentes (certidão de fls. 110/111 e FA de fls. 112/113), fixo as penas mínimas de dois anos de reclusão e dez dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência do réu Carlos, que, inclusive, é específica (condenações definitivas nos processos nº 0009091-18.2006.8.26.0451 da 2ª V.C. local e nº 0020028-53.2007.8.26.0451 dessa 1ª V. C. e em ambos ainda não cumpriu as penas, conforme fls. 164 e 163 da F.A., respectivamente. Também foi condenado pelo grave delito de tráfico de drogas no processo 0022139-34.2012.8.26.0451, novamente dessa 1ª V.C., cuja pena ainda está pendente de cumprimento (fls. 165 da F.A.). Por outro lado, Carlos tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime.

Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir suas penas na segunda fase.

Ozeias não tem agravantes contra si e tem em seu favor a atenuante da confissão, mas ela não autoriza a redução das penas aquém do mínimo.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em relação ao réu Carlos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, ou a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais. De fato, ele é portador de maus antecedentes e triplamente reincidente específico, o que, além de impedir tais benesses, nos termos do artigo 33, do Código Penal, impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da sua pena corporal.

Quanto ao réu Ozeias, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo sua pena corporal por duas restritivas de direitos, nas modalidades prestação de serviços à comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções.

Elegi as duas substitutivas, pois a pena corporal é superior a um ano e o crime questão (furto qualificado pelo concurso de agentes) é um dos que mais intranquiliza a sociedade, de modo que é necessária resposta firme do Estado para que as penas cumpram suas funções de prevenção e reprovação dos crimes.

Na hipótese de reversão de que trata o artigo 44, parágrafo 4º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena de Ozeias será o aberto.

Por não haver condições de se apurar a atual condição econômica dos réus, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO o réu CARLOS AUGUSTO HORACIO JUNIOR a cumprir dois anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar onze dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; e

2) CONDENO o réu OZEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA a cumprir dois anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade por igual período da pena cominada e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade assistencial da Comarca, a ser oportunamente indicada pelo Juízo das Execuções, e a pagar dez dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Conforme acima exposto, o réu Carlos ostenta maus antecedentes e é triplamente

reincidente, inclusive específico, o que denota real possibilidade de reiteração criminosa sendo necessária, portanto, a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a qual fica mantida.

Assim, recomende-se o réu Carlos na prisão em que se encontra, servindo-se a presente sentença como ofício.

Quanto ao réu Ozeias, primário e de bons antecedentes, ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo Representante do MP, RÉUS e DEFESA foi dito que NÃO DESEJA(M) RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^(a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.